

1501816-03.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... PÚBLICO pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta na denúncia que no dia 09 de junho de 2021, às 17h20, na Avenida Alto Araguaia, 560, Jardim Salles, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) invólucros de cocaína, totalizando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501816-03.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501816-03.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2156379/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 18406883 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

2802/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2156379 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

2802/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GUSTAVO CERNEVIVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

GUSTAVO CERNEVIVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta na denúncia que no dia 09 de junho de 2021, às 17h20, na Avenida Alto Araguaia, 560, Jardim Salles, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) invólucros de cocaína, totalizando o peso líquido de 38,96 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl.

14/15, laudo de constatação de fls. 17/19 e exame químico toxicológico de fls. 80/82.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Apurou-se que, os policiais militares durante patrulhamento, abordaram Adriano Valentim de Brito e em sua posse foi localizado 1 invólucros de cocaína, tendo ele confessado ter comprado para consumo próprio de um indivíduo chamado GUSTAVO em uma loja de pesca chamada Aruana. Em diligência, os policiais foram até o local indicado e se depararam com GUSTAVO em frente a loja, tendo ele corrido em direção ao interior do estabelecimento ao perceber que seria abordado, bem como dispensado um saquinho plástico ao chão. Ato contínuo, os policiais deteram o denunciado e verificaram que no saquinho plástico dispensado por ele, havia 36 invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) em dinheiro. Além disso, em sua residência foi encontrado 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) porção de pó branco, a qual GUSTAVO alegou utilizar para misturar com a cocaína, e diversos saquinhos plásticos vazios. Para os policiais, o denunciado confessou que estava vendendo drogas. Já na Delegacia de Polícia, ele negou a prática delitiva, alegando que a droga encontrada era pra consumo próprio.

Houve defesa preliminar (fls. 123/125).

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2021 em fl. 126.

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 132).

No curso da instrução processual foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado. Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas com fundamento no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal e, se este não for o entendimento, que seja ABSOLVIDO nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devida inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação. Subsidiariamente, a concessão de benefícios legais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha O.C. (fls. 04/05), policial militar, disse que em companhia de seu colega Soldado Anderson integravam a equipe Força Tática quando realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro São Francisco, ocasião em que abordaram a pessoa de ADRIANO VALENTIM DE BRITO no cruzamento da Avenida Daniel Soubhia com a Rua Jundiá. Que na posse de Adriano foi encontrado um invólucro do tipo "zip lock" contendo cocaína, tendo Adriano alegado que era usuário e que tinha comprado a droga há poucos instantes numa loja de artigos de pesca de nome "Aruana" e que tinha pego a droga do dono de nome Gustavo, conhecido pela alcunha de "Gordo". Que diligenciaram até a referida loja, localizada na Avenida Alta do Araguaia, nº560, onde se depararam com o indiciado GUSTAVO CERNEVIVA em frente a loja, tendo ele corrido em direção ao interior do estabelecimento ao perceber que seria abordado. O depoente o acompanhou e antes de detê-lo nos fundos da loja, viu que Gustavo dispensou invólucros de "zip lock" no chão e uma quantia em dinheiro, que em seguida verificou-se ser 36 invólucros com substância semelhante a cocaína e quantia de R\$ 248,00 em dinheiro. Que em vistoria no estabelecimento, também foi localizado um cartucho de espingarda intacto calibre 32. Durante a ocorrência, o genitor de Gustavo, de nome NILSON ANTONIO CASSIO CERNEVIVA, chegou no local e assumiu a responsabilidade pelo cartucho e disse que possuía duas espingardas calibre 32 e 36 e uma "garrucha velha" em sua casa, situada ao lado da loja, apresentando as referidas armas e mais 13 cartuchos cal. 32 intactos, 01 cal. 36 deflagrado e 02 cal. 32 deflagrados. Nilson apresentou os registros das espingardas, no entanto, com vencimentos no ano de 2012. Com relação a "garrucha" nenhum documento foi apresentado, sendo elaborada a ocorrência com a apreensão das

armas no RDO n. 2803/2021. Foi verificado que Gustavo também reside na casa do pai e em seu quarto foram encontrados 02 balanças de precisão, 01 porção de pó branco (que ele alegou que utilizava para misturar com cocaína) e diversos saquinhos "zip lock" vazios. Gustavo ainda confessou que vendia cada porção de cocaína pela quantia de R\$50,00, inclusive, quando necessário, recebia o pagamento de droga através de maquininha de cartão de crédito. Que diante dos fatos deram voz de prisão a Gustavo pelo crime de tráfico de drogas e foi cientificado sobre seus direitos constitucionais, em seguida conduzido a esta delegacia. Adriano também foi detido e conduzido a esta delegacia pelo delito de porte de entorpecente.

A testemunha A.P.M. (fl. 06), policial militar, disse que acompanhava o Cabo Class quando abordaram a pessoa de ADRIANO VALENTIM DE BRITO, que estava na posse de 01 invólucro de cocaína, tendo ele afirmado que tinha comprado de um tal de "gordo", dono de uma loja de materiais de pesca de nome "Aruana", no bairro Jardim Sales. Que diante dos fatos, deslocaram-se até a referida loja, situada na Avenida Alto do Araguaia, nº560, onde se depararam com o indiciado GUSTAVO CERNEVIVA em frente o local, o qual correu em direção ao interior da loja quando percebeu a aproximação dos policiais. Que juntamente com o Cabo Class foram ao seu encaixote, sendo possível visualizá-lo dispensando invólucros do tipo "zip lock" no chão, bem como uma quantia em dinheiro. Que abordaram o indiciado nos fundos da loja e verificaram que os invólucros dispensados continham substância semelhante a cocaína, totalizando 36 unidades e a quantia em dinheiro totalizou R\$ 248,00. E em vistoria na loja foi encontrado numa mesa um cartucho intacto cal.32. Durante a ocorrência o genitor do indiciado de nome NILSON ANTONIO CASSIO CERNEVIVA compareceu no local e assumiu a responsabilidade pelo cartucho e disse que possuía armas de fogo em sua casa, situada ao lado da loja, apresentando duas espingardas cal. 32 e 36, além 13 cartuchos cal. 32 intactos e 03 cartuchos deflagrados, sendo 01 cal. 36 e 02 cal. 32. Foi verificado que o indiciado também residia na casa do pai e em seu quarto foram encontradas 02 balanças de precisão, diversas embalagens "zip lock" vazias e 01 porção de pó branco, que o indiciado disse que utilizava para misturar na cocaína. Que informalmente o indiciado acabou confessando que comercializava drogas e que vendia cada porção de cocaína pela quantia de R\$ 50,00, inclusive, quando necessário, recebia o pagamento de drogas através de maquininha de cartão de crédito. Que diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o indiciado conduzido a este plantão policial, juntamente com Adriano e com seu genitor Nilson.

A testemunha A.V.B. (fl. 07) disse que é usuário de drogas há uns trinta anos, e nesta data foi abordado por policiais militares quando estava na posse de uma porção de cocaína e inquirido pelos policiais informou que adquiriu de "Gordo" de uma loja de pesca, que foi a primeira vez que comprou lá, que foi lá para comprar um anzol e ele lhe ofereceu um tirinho, e assim já comprou um saquinho por cinquenta reais, e assim foi conduzido até este plantão policial.

Interrogado, G.C. (fl. 08) disse que é usuário de drogas há uns onze anos, que policiais adentraram em seu estabelecimento e encontraram em sua posse seis invólucro de cocaína, pó, que não tinha feito a venda instantânea antes, que a balança que foi encontrada é utilizada na sua loja de pesca para vender chumbada e outros objetos por peso, e o saco com pó branco e utilizado para o preparo de isca de fígado para usar na pesca, e é essência de sabor leite condensado. Que o dinheiro era do comércio que possui. Quer deixar consignado que tem problemas nas pernas e de respiração, apneia.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação (fls. 17/19), pelo exame químico toxicológico (fls. 80/82) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

De proêmio cabe ressaltar que a Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti

Cruz, firmou a tese de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente".

Vale consignar que "A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado." (AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022).

A excepcionalidade da conduta policial está fincada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa.

Isto porque após a abordagem do acusado, seu pai informou aos policiais a presença de armas em sua residência e já no domicílio foram encontrados itens para a embalagem e preparo de drogas, não se tratando de mera suspeita, o que justificou a urgência da medida.

A busca pessoal exige fundada suspeita. O RHC 158580 / BA é bem ilustrativo:

"Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

Observa-se que a busca pessoal não se aperfeiçoou apenas e tão somente em razão do tirocínio policial, mas também porque após abordarem um usuário de drogas, este informou que havia comprado as drogas do acusado, bem como o acusado se assustou e tentou sair do local ao avistar a viatura, o que justificou a medida.

De se concluir, assim, que não se tratou de medida ilegal e abusiva, sob o nefasto pretexto de averiguação discriminatória, motivo pelo qual se afasta a tese da ilegalidade.

No mais, houve a produção de prova em juízo.

A testemunha O.C., policial militar, disse que abordaram um indivíduo anteriormente, Adriano, e em posse dele tinha um pino de cocaína. Ele disse que comprou de Gustavo numa loja de produtos de pesca. Em seguida, se deslocaram até o local e Gustavo estava na frente. Ao ver os policiais, ele dispensou parte da droga e conseguiram resgatar parte da droga. Também encontraram um cartucho de arma de fogo, que o pai dele disse que era dele. As armas tinha documento, vencidos. Também tinha munições intactas e deflagradas. Encontraram produto para mistura de droga, segundo Gustavo. Ele admitiu que vendia por cinquenta reais e fazia uso de máquina de cartão. Foi a primeira vez que o abordou.

O acusado G.C. disse que estava usando muita droga e pegava para vender também.

Estava vendendo a droga na loja. Não passou a máquina de cartão. Vendia no dinheiro. O comércio é de seu pai. O produto encontrado em sua casa era para aumentar a droga e vende-la. Nunca foi preso ou processado anteriormente.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Em breve síntese, a prova policial foi uníssona ao confirmar que, após a abordagem de um usuário, tomaram conhecimento de comércio ilícito de entorpecentes efetuado pelo acusado. Realizada a abordagem e revista pelo local constatou-se que no saquinho plástico, dispensado pelo acusado, foram localizados 36 invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) em dinheiro.

Demais disso, "A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como *delictum sui generis*, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio" (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010)

A quantidade de droga, sua variedade e forma de acondicionamento não denotam a finalidade de mero consumo próprio, especialmente porque encontrado em seu poder entorpecente fracionado e embalado, certo ainda que fora apreendido petrecho compatível com a comercialização, a exemplo da balança de precisão.

Além disso, o próprio acusado confessou que a droga tinha destinação para a venda a terceiro.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais. A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes. A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

A quantidade de entorpecente apreendido é o bastante para a configuração do delito, mas não para a majoração da pena.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, presente a atenuante da confissão espontânea e ausente agravantes.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 anos de reclusão.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de aumento da pena, porém merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. É que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há fundadas notícias de que ela se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Quanto ao redutor de pena, tenho que a quantidade de droga não destoa da normalidade, sendo que o contexto dos autos não revelou habitualidade delituosa, pelo que aplico o redutor em seu patamar máximo e justifica a diminuição da pena no quantum máximo de dois terços.

Desse modo, torno-a definitiva em 1 ano e 08 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, motivo

pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 500 dia-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'c', do CP.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. Como a pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente em crime doloso e estão preenchidas as circunstâncias judiciais, como acima apontadas, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Da pena substitutiva aplicada: Dentro do rol exaustivo previsto no art. 43 do Código Penal, aplicando-se analogicamente o entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a definição do quantum de aumento da pena base, a escolha justificada da pena restritiva de direitos está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Bem por isso, reputo suficiente a aplicação da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, como forma de retribuir à sociedade os danos provocados, reinserindo o sentenciado à comunidade, pelo mesmo tempo da pena aplicada, observando-se o disposto no art. 46 do Código Penal, que será individualizada no Juízo das Execuções Criminais.

E prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, com nítido caráter reparador, que melhor atenderá ao caráter ressocializador da reprimenda.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, vez que a substituição ocorrida lhe é mais favorável.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado GUSTAVO CERNEVIVA pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput e § 4º da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 500 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. Entretanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade por igual período (01 ano e 08 meses) e outra de prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo em favor de entidade com destinação social, nos termos do art. 44 c/c art. 45, § 1º e art. 46 do Código Penal.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Fls. 99: Concedo o benefício da justiça gratuita ao réu. Anote-se. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos (arts. 63-C e 63-D da Lei 11.343/06) em fls. 14. Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF.

Publicada e intimados em audiência.

Catanduva, 04 de agosto de 2022.

MARGEM DIREITA